

0001643-88.2018.8.26.0510

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CAIO CESAR GINEZ ALMEIDA BUENO

Comarca: Rio Claro

Foro: Foro de Rio Claro

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/05/2022

... Lei n. 11.343/2006 não afasta a hediondez do crime de tráfico de drogas".

Ocorre que, em sessão realizada no dia 23/06/2016, o Plenário do STF, por maioria de votos, no Habeas Corpus nº 118.533-MS, firmou entendimento no sentido de que o denominado tráfico privilegiado de drogas, previsto no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, não tem natureza hedionda.

Conforme ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Rio Claro

Foro de Rio Claro

2ª Vara Criminal

Avenida 05, nº 535, Rio Claro-SP - cep 13500-380

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

0001643-88.2018.8.26.0510 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0001643-88.2018.8.26.0510

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - RDO 1488/2018 - DEL.SEC.RIO CLARO PLANTÃO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Lucas Caldeira dos Santos

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAIO CESAR GINEZ ALMEIDA BUENO

Vistos.

LUCAS CALDEIRA DOS SANTOS, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso nas penas do artigo 33, "caput", da Lei Federal 11.343/06, porque em 18 de fevereiro de 2018, às 19h32, na rua 9-A esquina da avenida 62-A, altura do nº 1886, bairro São Miguel, nesta cidade e comarca de Rio Claro, o acusado, teria trazido consigo e guardado drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, consistentes em 26 eppendorfs com cocaína (peso líquido de 3,4g).

Auto de prisão em flagrante (fls. 02), boletim de ocorrência (fls. 18/21), auto de exibição e apreensão (fls. 22), laudo de constatação (fls. 24/25) e exame químico-toxicológico (fls. 91/93).

O acusado Lucas foi notificado por edital (fls. 105/106), apresentou resposta escrita (fls. 111/112) e a denúncia foi recebida (fls. 154/155).

Superada a instrução e a fase do art. 402 do Código de Processo Penal, as partes apresentaram suas alegações finais na forma de memoriais nos termos do art. 403, §3º, do Código de Processo Penal.

Em sede de memórias, o Ministério Público pugnou pela condenação do réu nos termos da denúncia e regime inicial semiaberto diante da quantidade de pena e das circunstâncias judiciais desfavoráveis. (fls. 205/208)

A Defesa, por seu turno, preliminarmente, arguiu a nulidade da abordagem em razão da usurpação das funções atribuídas à guarda municipal. No mérito, requereu a absolvição diante da fragilidade do quadro probatório, nos termos do art. 386, VII, do CPP. Subsidiariamente, requereu o reconhecimento da menoridade relativa, aplicação da causa de diminuição de pena do §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, bem como a aplicação do regime inicial aberto. (fls. 219/230)

É o relatório.
FUNDAMENTO E DECIDO.

De início, afasto a preliminar arguida pela Defesa de usurpação das atribuições pela guarda municipal.

A nulidade arguida limita-se à abordagem realizada anterior à prisão, no entanto, não há que se falar em usurpação das funções previstas no art. 144, §8º, da CF, senão vejamos.

Como se vê, os guardas municipais tomaram conhecimento através de uma denúncia anônima realizada por um transeunte de que indivíduo praticava, naquela ocasião, o delito de tráfico de drogas. Na sequência, deslocaram-se até o local e lograram êxito em localizar um indivíduo com as mesmas características descritas, que ao notar a aproximação dos municipais tentou empreender fuga e dispensou uma sacola plástica no solo.

Ora, não restam dúvidas de que a denúncia anônima realizada pelo transeunte foi o que deu suporte à legalidade da conduta dos guardas municipais de diligenciarem em busca do indivíduo que supostamente praticava a mercancia ilícita de drogas. Frisa-se, ainda, que tal denúncia foi reforçada, logo em seguida, pela fuga empreendida pelo réu ao notar a aproximação dos guardas municipais, tendo inclusive, dispensado uma sacola plástica contendo os entorpecentes.

Da análise dos elementos que culminaram na abordagem realizada pelos guardas municipais, tem-se que é decorrente do poder de polícia próprio do Poder Público, que tem por fim prevenir ou obstar atividades contrárias à ordem pública, com fundamento na lei, de modo que não ocorreu a alegada ilicitude na abordagem realizada no presente caso, pelo contrário, o que se vê é o regular exercício das suas competências legais como agentes auxiliares da segurança pública, conforme determina o art. 5º, inciso IV e XIV, do Estatuto das Guardas Municipais, senão vejamos:

"Art. 5º São competências específicas das guardas municipais, respeitadas as competências dos órgãos federais e estaduais:

[...]

IV- colaborar, de forma integrada com os órgãos de segurança pública, em ações conjuntas que contribuam com a paz social;

XIV - encaminhar ao delegado de polícia, diante de flagrante delito, o autor da infração, preservando o local do crime, quando possível e sempre que necessário. "

Desse modo, no presente caso, conforme alegado pela própria defesa, de fato, a conduta dos guardas municipais não tinha o escopo de proteger de bens, serviços e instalações municipais, mas sim de colaborar, no âmbito de sua competência específica, com os órgãos de segurança pública, devendo, portanto, ser afastada a preliminar arguida.

No mérito, a ação penal é procedente.

Atestado em ambos os laudos que a substância apreendida consiste em cocaína, o caráter entorpecente, necessário à configuração do crime de tráfico, restou devidamente demonstrado, nos termos do art. 50, §§ 1º e 2º, do art. 1º, parágrafo único, e do art. 66, todos da Lei nº 11.343/06.

A materialidade do delito está devidamente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 02), boletim de ocorrência (fls. 18/21), auto de exibição e apreensão (fls. 22), laudo de constatação (fls. 24/25) e exame químico-toxicológico (fls. 91/93).

Perante a autoridade policial o réu reservou-se ao direito de permanecer calado e se manifestar somente em juízo (fls. 06/07).

Em juízo, não compareceu, motivo pelo qual foi decretada sua revelia.

A testemunha comum, Dhieimison Pereira de Oliveira, guarda municipal, declarou que na data dos fatos realizavam patrulhamento no bairro Vila São Miguel, em Rio Claro, momento em que foram informados por uma senhora que pediu para não ser identificada, que Lucas Caldeira dos Santos, morador naquele bairro, vendia drogas na Av. 62-A. A mulher informou que Lucas vestia uma camiseta cinza e bermuda florida. Foram ao local indicado e avistaram um indivíduo vestido da mesma maneira como dito pela denunciante, o qual, ao notar que se aproximavam empreendeu fuga e dispensou um saco plástico no citado local. A equipe pegou a embalagem imediatamente e constatou que em seu interior havia 26 microtubos contendo cocaína. Enquanto isso, correu em perseguição ao indivíduo, que "pulou" o portão da casa localizada na Rua 10-A, no mesmo bairro, que se encontrava aberto e desocupado. Relatou que o proprietário residia nas proximidades e viu a movimentação das viaturas, então com o consentimento dele adentraram o local e encontraram o indivíduo trancado dentro do banheiro do imóvel. Indagado, Lucas informou que comercializava entorpecentes no local há um tempo e usaria o dinheiro a fim de adquirir maconha para seu consumo. Não se recorda se foi encontrado dinheiro com Lucas. (SAJ)

A testemunha comum, Maykel Henrique de Aguiar, guarda municipal, declarou que patrulhavam o bairro São Miguel, quando foram abordados por uma senhora que os informou que havia um indivíduo vendendo drogas na Avenida 62 com a rua 9-A. Diante das características repassadas pela senhora, foram ao local indicado e avistaram Lucas, o qual, ao notar a presença da viatura, empreendeu fuga. Nesse momento, percebemos que ele havia dispensado um saco plástico contendo microtubos com cocaína. Continuaram perseguindo-o e Lucas adentrou um imóvel que, de acordo com populares, estava desocupado. Conseguiram contato com o proprietário do imóvel, o qual franqueou a entrada. Ao adentrar o imóvel, perceberam que Lucas estava trancado dentro do banheiro, tendo o proprietário dito que se fosse necessário, poderiam arrombar a porta. Conseguiram abrir a porta, identificaram Lucas, e indagado, ele confessou que estava vendendo as drogas naquela noite. Não o conhecia. Afirmou que Lucas apresentava as mesmas características informadas pela senhora que os abordou, bem como ela estava próxima ao local em que Lucas foi visto. Não se recorda se foi encontrado dinheiro com Lucas. Não havia ninguém próximo a ele. (SAJ)

A testemunha de defesa Adilson Chiovetto declarou que não tem nenhuma ligação com Lucas. Informou que na data dos fatos o acusado, empreendendo fuga, se escondeu dentro de um de seus imóveis, o qual estava alugado. A inquilina havia saído e deixado a janela aberta, de forma que Lucas conseguiu pular o portão e a janela para se esconder dentro do imóvel. Ele reside ao lado da residência citada e foi chamado pelos guardas para abrir o portão e franquear a entrada deles, mas não os acompanhou dentro da residência. Não viu se os guardas encontraram drogas ou dinheiro com o acusado, bem como não escutou a versão deste para as autoridades. Presenciou os guardas saindo com o acusado já algemado e o colocando na viatura. Negou já ter tido contato com o réu anteriormente aos fatos. (SAJ)

Pois bem. Verifica-se que o conjunto probatório associado aos elementos colhidos na fase inquisitiva confirmam a prática do delito de tráfico de entorpecentes pelo réu.

Os guardas municipais foram firmes e seguros em suas declarações.

Anoto que os depoimentos dos agentes públicos merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral, eis que inexistem elementos dos quais se possa extrair que tinham a intenção de incriminar indevidamente o réu, não pesando sobre eles nenhuma suspeição.

Ademais, por se tratar de agentes públicos investidos em cargos cujas atribuições se ligam essencialmente à segurança pública, com o fim de manter a ordem e o bem estar social, não têm qualquer interesse em prejudicar inocentes, principalmente quando os relatos apresentados são coerentes e seguros, como no caso dos autos.

Nesse sentido já se decidiu:

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações." (STF, HC 87.662-5/PE, Rel. Min. Carlos Ayres Britto, d.j. 05/09/06, DJU 16/02/07 - grifamos);

"O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso." (STJ, HC 165561/AM, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 15/02/2016);

"Furto - Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em declarações coerentes e harmônicas da vítima e dos policiais - Validade. Nos crimes de furto a palavra dos ofendidos e das testemunhas é crucial à elucidação dos fatos, sendo válida também para a caracterização de eventuais qualificadoras. No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm ainda deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário." (TJSP, apelação nº 0001005-35.2014.8.26.0077, 8ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Grassi Neto, d.j. 17/03/2016 - grifamos).

Com efeito, as provas coligidas aos autos dão conta do envolvimento do réu com o tráfico, pois os relatos dos guardas municipais são seguros nesse sentido, tudo estando a revelar que estava envolvido com a prática da mercancia ilícita de drogas e não se vislumbra que os guardas tivessem inventado isso apenas para prejudicar inocente.

Os relatos dos guardas municipais convergiram no sentido de que realizavam patrulhamento no bairro Vila São Miguel, momento em que foram informados por uma senhora, que pediu para não ser identificada, de que o réu vendia drogas. Após se dirigirem ao local indicado avistaram o réu, que vestia a mesma roupa informada pela denunciante. Ao notar a presença da viatura, o réu empreendeu fuga e dispensou um saco plástico contendo 26 microtubos de cocaína.

Os guardas municipais também esclareceram que houve a perseguição do réu, que "pulou" o portão de uma casa localizada na Rua 10-A, que se encontrava aberta e desocupada. Com o consentimento do proprietário desse imóvel, que residia nas proximidades, adentraram na residência e encontraram o réu trancado no banheiro. Informaram, ainda, que o réu, após ser indagado, reconheceu que comercializava entorpecentes no local há um tempo e usaria o dinheiro para adquirir maconha para consumo próprio.

Conforme demonstrado, diante da aproximação da guarda municipal o réu empreendeu fuga para o interior de uma residência. Ora, se não tivesse nada para esconder não haveria razão para fugir e se esconder no imóvel.

As drogas foram encontradas no interior da sacola plástica dispensada pelo réu antes de empreender fuga e estavam embaladas individualmente e prontas para o comércio.

Além disso, não houve comprovação nos autos de que o réu estava no local dos fatos com outra finalidade que não a de praticar o tráfico de drogas.

Veja-se o réu sequer compareceu em juízo para apresentar sua versão sobre os fatos.

De outro lado, a própria testemunha de defesa Adilson confirmou que na data dos fatos o acusado empreendeu fuga e se escondeu no interior de um dos seus imóveis que estava alugado. Explicou que a inquilina havia saído e deixado a janela aberta, de modo que Lucas conseguiu pular o portão e a janela para se esconder no interior.

Desse modo, a existência de prévia notícia acerca da traficância no local exercida pelo réu, a atitude dele após a aproximação dos guardas municipais, a localização de drogas na sacola dispensada por ele, embaladas individualmente, aliadas às declarações harmônicas prestadas pelos guardas municipais, demonstram que as drogas apreendidas pertenciam ao réu e se destinavam à mercancia ilícita, restando afastada a pretensão de desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/06.

Assim, contrariamente ao que foi sustentado pela Defesa, certo é que as provas são robustas para sustentar um decreto condenatório, de forma que a responsabilização do réu pelo delito previsto no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06 é medida de rigor.

Acolhida, portanto, a tese acusatória, passo, com fulcro nos artigos 59 e 68 do Código Penal, à fixação da pena do réu.

Respeitado o sistema trifásico, fixo a pena base do réu no mínimo legal, diante da ausência de circunstâncias hábeis a majorá-la. Assim, sua pena inicial será de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a atenuante da menoridade relativa. No entanto, deixo de reduzir a pena do réu aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, observo a causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06. O réu é tecnicamente primário e portador de bons antecedentes. Não há notícias nos autos de que se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa. Destarte, de rigor a redução da pena em seu grau máximo, qual seja, em 2/3, de maneira que passará a 01 ano e 08 meses de reclusão e 166 dias-multa. Não há outras causas de aumento ou de diminuição, de forma que torno a pena acima fixada definitiva.

O reconhecimento da referida causa de diminuição de pena, denominada "tráfico privilegiado", traz novas consequências aos réus condenados pela prática dessa modalidade de crime, diante do recente entendimento sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça.

A Súmula 512 do STJ, editada em 11 de junho de 2014, após o julgamento do REsp 1.329.088/RS - de relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, dispunha que "A aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 não afasta a hediondez do crime de tráfico de drogas".

Ocorre que, em sessão realizada no dia 23/06/2016, o Plenário do STF, por maioria de votos, no Habeas Corpus nº 118.533-MS, firmou entendimento no sentido de que o denominado tráfico privilegiado de drogas, previsto no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, não tem natureza hedionda.

Conforme esposado pela Ministra Relatora do acórdão, Cármen Lúcia, somente as figuras delitivas definidas no artigo 33, "caput" e §1º, da Lei 11.343/2006 seriam equiparadas aos crimes hediondos, considerando que o delito na modalidade privilegiada apresentaria "contornos mais benignos, menos gravosos, notadamente porque é relevado o envolvimento ocasional do agente com o delito, a não reincidência, a ausência de maus antecedentes e a inexistência de vínculo com organização criminosa".

Embora o referido julgamento proferido pelo Pleno do STF não tenha efeito vinculante nem eficácia erga omnes, a Terceira Seção do STJ acolheu a tese segundo a qual o tráfico ilícito de drogas na sua forma privilegiada (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006) não é crime equiparado a hediondo e decidiu revisar o entendimento consolidado no julgamento do REsp nº 1.329.088/RS - Tema 600, cancelando o enunciado da Súmula 512, em observância aos princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia, conforme segue:

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS NA SUA FORMA PRIVILEGIADA. ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. CRIME NÃO EQUIPARADO A HEDIONDO. ENTENDIMENTO RECENTE DO PLENO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NO JULGAMENTO DO HC 118.533/MS. REVISÃO DO TEMA ANALISADO PELA TERCEIRA SEÇÃO SOB O RITO DOS REPETITIVOS. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA Nº 1.329.088/RS. CANCELAMENTO DO ENUNCIADO Nº 512 DA SÚMULA DO STJ. 1. O Supremo Tribunal Federal, no recente julgamento do HC 118.533/MS, firmou entendimento de que apenas as modalidades de tráfico ilícito de drogas definidas no art. 33, caput e § 1º, da Lei nº 11.343/2006 seriam equiparadas aos crimes hediondos, enquanto referido delito na modalidade privilegiada apresentaria "contornos mais benignos, menos gravosos, notadamente porque são relevados o envolvimento ocasional do agente com o delito, a não reincidência, a ausência de maus antecedentes e a inexistência de vínculo com organização criminosa." (Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 23/06/2016). 2. É sabido que os julgamentos proferidos pelo Excelso Pretório em Habeas Corpus, ainda que por seu Órgão Pleno, não têm efeito vinculante nem eficácia erga omnes. No entanto, a fim de observar os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia, bem como de evitar a prolação de decisões contraditórias

nas instâncias ordinárias e também no âmbito deste Tribunal Superior de Justiça, é necessária a revisão do tema analisado por este Sodalício sob o rito dos recursos repetitivos (Recurso Especial Representativo da Controvérsia nº 1.329.088/RS – Tema 600). 3. Acolhimento da tese segundo a qual o tráfico ilícito de drogas na sua forma privilegiada (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006) não é crime equiparado a hediondo, com o consequente cancelamento do enunciado 512 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça.” (STJ, Pet 11.796-DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, d.j. 23/11/2016)

Nesse sentido, já decidiu o C. TJSP:

“Habeas corpus. Pedido de progressão de regime. Suspensão do feito pelo Juízo das Execuções, com fulcro no art. 1.037, II, do CPC. Superior Tribunal de Justiça que julgou questão de ordem, cancelou a súmula nº 512 e firmou entendimento de que o tráfico privilegiado não mais é classificado como crime hediondo. Liminar confirmada. Ordem parcialmente concedida.” (HC 2241449-61.2016.8.26.0000, Des. Rel. Luiz Fernando Vaggione, Bauru, 2ª Câmara de Direito Criminal, d.j. 19/12/2016)

Destarte, não há mais óbice à fixação de regime prisional diverso do fechado para o condenado pela prática do crime de tráfico de drogas privilegiado, tampouco à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou à suspensão da execução desta.

No presente caso, considerando que as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal favorecem o réu, diante de sua primariedade e bons antecedentes, fixo o regime inicial aberto para cumprimento da pena.

Presentes os requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal, e considerando a Resolução nº 05/2012 do Senado Federal, que suspendeu a execução da expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos" do § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas, em razão da declaração incidental de inconstitucionalidade desta proibição pela referida Corte de Justiça na apreciação do Habeas Corpus nº 97.256/RS, substituo a pena privativa de liberdade aplicada por duas restritivas de direitos, quais sejam, a prestação de serviços à comunidade na razão de uma hora de trabalho por dia de condenação e prestação pecuniária equivalente a um salário mínimo a ser revertida para entidade de caráter social.

Diante da ausência de elementos acerca da situação financeira do réu, fixo o valor do dia multa no mínimo legal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal que a Justiça Pública move contra LUCAS CALDEIRA DOS SANTOS para CONDENÁ-LO às penas de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, fixados no mínimo legal, pela prática do crime previsto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06. Substituo a pena privativa de liberdade pelas restritivas de direitos de prestação de serviços à comunidade na razão de uma hora de trabalho por dia de condenação e prestação pecuniária equivalente a um salário mínimo a ser revertida para entidade de caráter social, nos termos da fundamentação.

O réu terá o direito de apelar em liberdade.

Determino a destruição das drogas, caso ainda não tenha sido feita.

Custas “ex lege”.

P.I.

Rio Claro, 23 de maio de 2022.

CAIO CESAR GINEZ ALMEIDA BUENO
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA